

1505576-29.2019.8.26.0358

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505576-29.2019.8.26.0358 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505576-29.2019.8.26.0358

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2134001/2019 - DEL.POL.JACI, 2946688 - DEL.POL.JACI, 1121/19/413 - DEL.POL.JACI, 2134001 - DEL.POL.JACI, 1121/19/413 - DEL.POL.JACI, 2134001 - DEL.POL.JACI, 1121/19/413 - DEL.POL.JACI, 2134001 - DEL.POL.JACI, 1121/19/413 - DEL.POL.JACI, 2134001 - DEL.POL.JACI, 1121/19/413 - DEL.POL.JACI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELQUIONE DOS SANTOS CRUZ

Juiz de Direito: Dr. ANDRE DA FONSECA TAVARES

Vistos.

ELQUIONE DOS SANTOS CRUZ, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 17 de abril de 2019, por volta das 20h40 min., na Rua Maria Joana do Amaral Mendonça, nº 950, Centro, no município de Jaci, o acusado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico ilícito, vendeu e forneceu 05 (cinco) porções de cocaína na forma de "crack", com pelo líquido de 0,52g para Flávia Cristina Gimenes da Silva e Roberto Sanches Miguel.

O acusado foi notificado, apresentou resposta à acusação e a denúncia foi recebida no dia 28 de agosto de 2020. O acusado foi devidamente citado. Houve audiência de instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa.

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

A materialidade do crime restou comprovada pelo Termo de Declarações (fls.09, 11, 13, 23/24, 34, 40, 59), pelos Autos de Interrogatórios (fls.45), pelo Boletim de Ocorrência (fls.05/08), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.15), pela ficha de atendimento médico (fls. 17/18), pelo Laudo Pericial (fls.19/21, 32/33), pelo Relatório Final da Autoridade Policial (fls.67/69), bem como pela prova oral produzida.

Passo à análise da autoria.

A testemunha FLÁVIA falou na delegacia que "chamou pela ambulância porque estava sentindo fortes dores de cabeça. Ao chegar no hospital entrou para tomar um soro, enquanto seu convivente permaneceu do lado de fora. Que tanto a declarante quanto seu convivente são usuários de crack. Dia que havia feito contato com Elquione momentos antes de ir para o hospital porque queria comprar crack e sabe que ele vende. Elquione foi até o hospital e entregou cinco pedras ao convivente da declarante que pagou por elas R\$ 50,00 e as guardou na carteira dentro da bolsa da declarante; com a chegada da policia, indagada negou, mas acabou dizendo que tinha comprado de Elquione e que estava na carteira; informa que é a quinta vez que adquire crack de Elquione e as cinco vezes foram desta mesma forma." Em Juízo não foi ouvida.

A testemunha ROBERTO falou na delegacia que "nesta data, por volta das 20:00 horas, sua convivente acionou a ambulância porque estava sentindo fortes dores de cabeça. Ao chegarem no hospital sua convivente entrou para tomar um soro, enquanto o declarante permaneceu ao lado de fora fumando um cigarro de palha. Informa que tanto o declarante quanto sua convivente são usuários de crack. Que antes de saírem para o hospital a convivente do declarante entrou em contato com Elquione porque queria comprar crack e ele disse que ia até lá para entregar. Elquione foi até o hospital e entregou cinco pedras ao declarante que pagou por elas R\$ 50,00, guardando-as na carteira dentro da bolsa da sua convivente; logo depois a policia chegou e entrou no hospital; momentos depois saiu e indagou ao declarante se este havia comprado crack, tendo respondido que sim. O policial mostrou uma foto de Elquione e perguntou se havia sido deste que havia comprado a droga e o declarante respondeu que sim; em seguida, foram colocados na viatura e se dirigiram até a casa de Elquione, mas ficou distante; ato continuo foram todos apresentados neste núcleo; informa que é a quinta vez que adquire crack de Elquione e as cinco vezes foram desta mesma forma." Em Juízo não foi ouvido.

A testemunha JOSÉ LUIZ falou na delegacia que "trabalha como motorista de ambulância e o casal Flávia e Roberto começaram a aciona-los toda quarta feira entre às 00:00 horas e 01:00 hora. Toda vez que buscava o casal, Flavia alegava que precisava ir ao hospital em razão de dores nas costas, sendo que quando lá chegavam, Flávia entrava para ser atendida enquanto Roberto se afastava e pegava algo com o indivíduo que conhece pelo nome Elquione. Diante disso, o depoente começou a desconfiar da situação e resolveu que acionaria a policia militar no caso de o casal novamente chamar a ambulância. Como isso ocorreu na quarta feira seguinte, o depoente fez contato com a policia militar, a qual compareceu ao local e abordou o casal, após Roberto já ter pego algo de Elquione. Durante a abordagem, presenciada pelo depoente, foi localizado entorpecentes com Flávia, sendo que esta disse ao policial que Roberto a agredia fisicamente para que ela participasse disso

e fossem pegar drogas com Elquione. O depoente não escutou Roberto dizendo nada. " Em Juízo confirmou sua declaração, acrescentou ainda que "não conhecia o réu, mas sim a FLÁVIA e o ROBERTO. Nunca presenciou ROBERTO pegando a droga".

O policial militar RAUSER falou na delegacia que "recebeu uma denúncia do motorista de ambulância José Luiz de que com frequência o casal Flávia e Roberto acionavam a ambulância para prestar socorro em uma propriedade rural sob alegação de que Flávia sentia fortes dores na cabeça e pelo corpo, necessitando, assim de atendimento médico. Entretanto, quando chegavam ao hospital, enquanto Flávia entrava e procurava atendimento, Roberto permanecia ao lado de fora e se encontrava com o indivíduo de nome Elquione, o qual lhe entregava algo. Na data dos fatos, novamente isso ocorreu, motivo pelo qual o motorista fez contato com a polícia militar e para lá se deslocou e realizou abordagem do casal. Em revista na bolsa de Flávia foi localizado, dentro da carteira, cinco pedras de substância que aparentavam ser crack. Indagada a respeito, ela declarou que fez contato via telefone com Elquione para que ele levasse drogas para eles defronte ao hospital. Ainda, Flávia afirmou que deu a quantia de R\$50,00 para Roberto entregar a Elquione no momento em que este lhe vendesse a droga. Roberto confirmou que comprou cinco pedras de crack de Elquione pelo valor de R\$50,00. Após foi realizada diligência no endereço de Elquione, sendo este encontrado na frente da residência, porém, ao perceber a aproximação da viatura da polícia, empreendeu fuga. No momento em que conseguiram abordá-lo, ele desobedeceu e resistiu, sendo necessário o uso de força física moderada, bem como utilização de algemas. Ademais, durante tal abordagem, familiares do acusado avançaram contra a equipe policial, momento em que o policial militar Adriano acabou sendo ferido. Controlada a confusão foi dado voz de prisão para Elquione e todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão policial. Não foi localizado nada de ilícito com Elquione". Em Juízo confirmou sua declaração, acrescentou ainda que "conheciam o réu pela prática do tráfico. a casa dele é 350 a 400m do hospital. a ocorrência foi 20:40h aproximadamente ".

O policial militar ADRIANO na delegacia confirmou a versão de seu colega de farda Rauser. Em Juízo confirmou sua declaração, acrescentou ainda que "demoraram uma ou duas horas pra chegar na casa do réu".

O réu ELQUIONE, na delegacia de polícia, disse que "desconhece as pedras de crack ora apresentadas e esclarece que é usuário de maconha. No dia do fato, saiu de um barzinho com destino a sua casa quando deparou com a equipe da polícia militar que o abordou e nada foi localizado. Foi liberado e quando já estava em casa, nega que empreendeu fuga e foi abordado novamente e nada de ilícito foi localizado. Que houve um tumulto na frente de sua casa, mas não viu o policial ser atingido. Nega que seja traficante e que não tem passagens criminais." Em juízo, o réu disse que NÃO é verdadeira a acusação. Contou que "foi abordado pelo PM RAUSER primeira vez e nada foi encontrado. Depois quando estava deitado, com criança em casa, os PMS chegaram entrando e pisando. Não reagiu".

Portanto, diante do que restou apurado, de rigor a procedência da ação penal.

O réu negou o crime, mas não apresentou nada que poderia justificar falsa acusação dos policiais e de todas as testemunhas contra ele.

Já os policiais foram firmes e uníssonos em seus depoimentos. Deram a mesma versão em juízo e na delegacia. Não há, ainda, qualquer razão para se duvidar do relato dos agentes públicos, que não teriam motivos para acusarem os réus injustamente, sendo seus testemunhos válidos, com o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, sendo inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e quando corroborado com os outros elementos de prova.

A testemunha José Luiz disse que Flávia e Roberto acionavam a ambulância, e chegando ao hospital via Elquione entregando algo para eles, o que o fez desconfiar, e, tanto Roberto quanto Flávia, na fase policial, confirmaram que compraram por cinco vezes "crack" de Elquione, sempre da mesma forma, ou seja, acionavam a ambulância e no local pegam o entorpecente com o réu.

O exame químico-toxicológico (fls.19/21) realizado nos entorpecentes encontrados com Tatiana e Roberto resultou em positivo para COCAÍNA, substância de uso proscrito no Brasil.

Observo que a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento demonstra a

finalidade diversa do simples uso. Fica afastada, portanto, a tese para uso próprio, sendo irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele.

Importante registrar também que é desnecessária a demonstração da comercialização da droga no momento do flagrante para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo)... não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram à sociedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinadas tipos de drogas". (Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. 2007, Editora Revista dos Tribunais, p. 314/315).

Ou seja, é punida a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, portanto, não há necessidade de efetiva prática do ato de comércio da substância entorpecente com a finalidade de venda.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES DEFENSIVAS: I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. II) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. III) REESTRUTURAÇÃO DA PENA. IV) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu guardava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico. 2. As provas produzidas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo como acolher a pretendida desclassificação da conduta para a de uso próprio. 3. O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública, não se restringindo à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. 4. Inviável o acolhimento da pretendida reestruturação da pena, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que já fixada no patamar mínimo legal, após análise esmerada de cada um dos moduladores descritos no art. 59, do CP. 5. Impossível prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, eis que o acusado, na fase policial, silenciou-se e, em juízo, apesar de admitir que a droga era de sua propriedade, alegou que seria destinada ao uso e não ao tráfico, crime este pelo qual restou condenado... O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Esse delito não se restringe à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade. Daí porque não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância". (Apelação Criminal 1.0480.11.006978-2/001; 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR WALTER LUIZ DE MELO; j. 28/08/2012).

Ainda: "TÓXICOS - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A SUA APLICAÇÃO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CPB - CABIMENTO NO CASO CONCRETO. - Se, apesar de o réu negar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as provas são aptas a comprovar os fatos havidos na denúncia, correta é a condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. - A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para tornar a conduta atípica, uma vez que o delito de tráfico, enquanto delito de perigo abstrato, apresenta grande lesividade à saúde e à incolumidade pública, o que não pode ser graduado somente pela quantidade de entorpecente apreendida. - Os

depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. - A fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, deve ser fixada de acordo com as regras do art. 59 do CPB daquela norma antidrogas. - Adotando o novo entendimento disposto quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cabível é a concessão do regime prisional diverso do fechado nos casos de tráfico privilegiado. - Preenchidos os requisitos legais, cabe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo no caso de tráfico de entorpecentes.". (Apelação criminal nº 1.0079.10.610239-9/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR CATTÁ PRETA, j. 04/09/2012).

Diante de todo o exposto, considero que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, verifico que o réu possui anotações (fls.219/220), assim fixo a pena acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, nada há que ser considerado, apesar de ostentar anotações o réu é tecnicamente primário.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é tecnicamente primário. Assim reduzo aquém do mínimo, em 2/3, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

À mingua de outras causas modificadoras da pena, torno a pena acima a pena definitiva.

O regime carcerário será inicialmente o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo o réu primário.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

Por fim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Em caso de descumprimento do benefício iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (artigo 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa do ofendido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e assim CONDENO o réu ELQUIONE DOS SANTOS CRUZ, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, e, reconhecido o privilégio do §4º do mesmo dispositivo legal, a cumprir a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial ABERTO. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação. As penas pecuniárias deverão ser atualizadas pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, §2º do Código Penal.

Verifico que os entorpecentes apreendidos (Fls. 15) já tiveram sua destinação determinada às folhas 76/77. Cumpra-se.

Custas "ex lege". Ao defensor nomeado, arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça-se certidão.
P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe
Mirassol, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA